

1501012-90.2019.8.26.0007

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... sentido é o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EMBASADO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. EXPRESSA DESCONFORMIDADE COM A REGRA PREVISTA NO ARTIGO 155 DO CPP. OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020'

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501012-90.2019.8.26.0007 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501012-90.2019.8.26.0007

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2148815/2019 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 5369214 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 10/19/360 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 2148815 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 10/19/360 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 2148815 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 10/19/360 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 2148815 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 10/19/360 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 2148815 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 10/19/360 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 2148815 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 10/19/360 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 2148815 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 10/19/360 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

SILVIO BERTACCHI FILHO, ARLINDO DE SOUZA E SILVA NETO e DAVID HAISLAN GOMES DE PAULA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 30 de dezembro de 2018, em horário indeterminado, porém no período vespertino, no

interior do estabelecimento comercial com nome fantasia "Ponto Frio", localizado no interior do Shopping Metrô Itaquera, situado na Avenida José Pinheiro Borges, nº 50, no bairro de Itaquera, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, DAVID HAISLAN GOMES DE PAULA, qualificado indiretamente a fls. 116/118, com fotografia a fls. 88; SILVIO BERTACCHI FILHO, qualificado e interrogado a fls. 172, com fotografia a fls. 86, e ARLINDO DE SOUZA E SILVA NETO, qualificado e interrogado a fls. 262/264, com fotografia a fls. 89, juntamente com outro indivíduo não identificado, atuando previamente combinados, com unidade de designios e identidade de propósitos, em concurso, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um total de 145 (cento e quarenta e cinco) aparelhos celulares de marcas e modelos diversos, não recuperados, totalizando, aproximadamente, o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pertencentes à empresa vítima "Ponto Frio".

Segundo a exordial, DAVID, SILVIO, ARLINDO e um comparsa não identificado combinaram em assaltar a loja do "Ponto Frio" situada no interior do Shopping Metrô Itaquera. Dessa forma, no dia dos fatos, adentraram ao referido estabelecimento comercial, simulando serem clientes sendo que, um deles vestia uma camiseta da Operadora TIM, aduzindo que gostaria de adquirir um aparelho celular. Contudo, nesse instante, os demais indiciados e o comparsa não identificado se aproximaram e anunciaram o assalto, exercendo grave ameaça mediante o uso de arma de fogo. Assim, subtraíram todos os aparelhos celulares em estoque e se evadiram do local. Ocorre, todavia, que, policiais civis investigavam uma associação criminosa especializada em roubos a lojas de aparelhos celulares em Shopping Centers, tal como o ocorrido no Shopping Internacional de Guarulhos/SP. Dessa forma, com o avanço das investigações, foi possível identificar as possíveis autorias do roubo praticado no interior do Shopping Metrô Itaquera. Nesse sentido, funcionários da empresa vítima, que trabalhavam na loja no momento do assalto, foram convidados a proceder ao reconhecimento fotográfico dos indiciados, resultando o ato como positivo.

Na denúncia foram arroladas as testemunhas LEILA PADUA HOLANDA, ANGELA APARECIDA DA SILVA SANTOS, SULIVAN SOUZA DE JESUS, HENRIQUE RAFAEL DANTAS GOMES, FAUSI PRATES EL KADRI, EVERTON VALERIANO DA SILVA e CLAUDIO TADASHI SATO GAZAFI e a vítima LUCIANO DA SILVA LEÃO.

Recebida a denúncia em 17/11/2021 às fls. 345/346.

Os réus DAVID, ARLINDO e SILVIO foram citados (fls. 390, 392 e 395, respectivamente).

Resposta à acusação oferecida pela Defensoria Pública fls. 398. Nessa oportunidade, foram arroladas as mesmas testemunhas da acusação.

Afastada a possibilidade de absolvição sumária e mantido o recebimento da denúncia (fls. 400/402), foi designada data para audiência de instrução e julgamento (fls. 440/441).

A vítima LUCIANO DA SILVA LEÃO foi devidamente intimada a fls. 456.

As testemunhas HENRIQUE RAFAEL DANTAS GOMES, SULIVAN SOUZA DE JESUS e LEILA BATISTA PÁDUA foram devidamente intimadas para a audiência (fls. 460, 465, 454 respectivamente).

Os policiais civis FAUSI PRATES EL KADRI, CLAUDIO TADASHI SATO GAZAFI e EVERTON VALERIANO DA SILVA foram devidamente requisitados para audiência (fls. 490/491).

Os réus SILVIO, DAVID e ARLINDO foram devidamente intimados para a audiência (fls. 458, 439 e 437, respectivamente).

O réu DAVID constituiu defensor a fls. 470.

Certidões criminais do acusado juntada ARLINDO a fls. 292/297, sendo o réu reincidente e com maus antecedentes, SILVIO as fls. 317/323, sendo o réu reincidente e com maus antecedentes, DAVID as fls. 339/340, primário.

Em audiência, foram ouvidas a vítima, as testemunhas, bem como o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal nos termos da denúncia.

Por seu turno, as defesas pleitearam a absolvição do réu por falta de provas.

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de Roubo.

O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo: Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel mediante violência ou grave ameaça, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída mediante o uso da força efetiva ou potencial direcionada contra outra pessoa com a finalidade de obtê-la para si ou para terceira pessoa, o que constitui seu elemento subjetivo específico. Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida. A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/19), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 20/25), termo de declarações e interrogatório (fls. 44), e, sobretudo, pela prova oral colhida.

O mesmo não é possível dizer da autoria.

Na delegacia, os réus negaram envolvimento com o crime.

Em juízo, o réu SILVIO BERTACCHI FILHO utilizou seu direito constitucional ao silêncio.

Em juízo, o réu ARLINDO DE SOUZA E SILVA NETO disse que não fez o roubo dos fatos. Disse que estão imputando crimes de épocas que até estava preso. Está sendo colocado como réu em crimes parecidos. Quando os policiais fizeram a investigação, disseram que se confessasse ele levaria a pena mínima, porém foi condenado a 18 anos, e depois disso vários processos passaram a imputar o réu. Foi preso em 2019 dentro da Igreja.

Em juízo, o réu DAVID HAISLAN GOMES DE PAULA disse que já foi em duas audiências em BO diferentes com os corréus mas foi absolvido, falando que fazia parte da quadrilha. Não faz. Na data dos fatos estava na praia com a família foi dia 27 e voltou dia 03. Nas fotos da investigação mostram os rapazes das câmeras de segurança e no caso dele pegaram a foto so Instagram. Ângelo é o careca tio da sua esposa e o Alexandre acha que é um primo de 3º grau da sua esposa. O apelido dele é Xandi, a sua esposa chama ele por esse apelido.

A versão dada pelos réus não foi afastada pelas demais provas acostadas aos autos. Na delegacia a testemunha Leila afirmou não se recordar das características dos assaltantes não sendo possível realizar o reconhecimento (fls. 71/72)

A testemunha LEILA BATISTA PÁDUA contou que no ano teve dois assaltos, um de manhã que estava presente. Estava sentada na frente atendendo um cliente quando um rapaz chegou falando "perdeu", ficou nervosa, ele foi com o pessoal do fundo enquanto a depoente ficou na frente. Eram 3 ou 4 agentes. O moço que tinha entrado estava armado o que foi render o pessoal. O que a rendeu não estava, não lembra. Ele ficou de frente mas se ver não sabe quem é. Eles levaram celular e notebook, não sabe o valor do prejuízo, mas foram 3 malas. Foi na delegacia prestar depoimento. Acha que mostraram umas fotos na delegacia mas não reconheceu ninguém. Hoje não reconheceu os réus. Acha que os objetos não foram recuperados. Disse trabalha de manhã, entra as 10h até as 18:20h. O roubo que aconteceu a tarde não estava.

A testemunha ANGELA APARECIDA DA SILVA SANTOS teria reconhecido na delegacia os réus Silvio e Arlindo por meio fotográfico, porém não foi ouvida em juízo.

A testemunha SULIVAN SOUZA DE JESUS asseverou que foi muito rápido, cerca de 4 ou 5 minutos, o pessoal entrou na loja e disse que se se mexesse iriam matar e que não era para olhar para a cara deles, então não olhou e não reconhece os agentes. Falaram que tinha mais de 20 que tinham pessoas do lado de fora. Um deles falou que estava rmado, levantou a camiseta e falou que se reagissem iam meter bala. Não viu a arma. Depois tiveram outros assaltos cometidos por pessoas diferentes. Não foi na delegacia fazer reconhecimento nem por foto. Levaram ceular, bolsa, mas como não tem acesso ao estoque não sabe dizer.

A testemunha HENRIQUE RAFAEL DANTAS GOMES disse que tiveram dois assaltos no local. Disse que estava na loja, por volta das 14h, foram abordados, pediram para entrar no estoque e levaram os celulares. Lembra que eram cerca de 3 pessoas, um dele estava armado. Olhou muito pouco para o rosto deles. Na delegacia mostraram um

livro mas não reconheceu ninguém. Se reconheceu na época acredita que tenha reconhecido. Viu pouco o rosto. Hoje não reconhece ninguém. Não sabe a quantidade de objetos levados, mas foram muitos. A ação no máximo durou 10 minutos. Acha que a Leila e o Sullivan foram fazer reconhecimento. Passou por 3 assaltos, então deve estar trocando um pelo outro. Primeiro registram tudo que foi roubado, não sabe porque demoraram 3 dias para registrar a ocorrência do roubo.

Da mesma forma a vítima Henrique disse em sede inquisitorial ter reconhecido os três réus, porém em juízo não pode confirmar quem seriam os assaltantes e nem se recordou ao certo como foi o reconhecimento (fls. 80).

Assim, tem-se que os reconhecimentos FOTOGRÁFICOS feitos perante a autoridade policial não se confirmaram em juízo e, se não bastasse, verifica-se que o fato ocorreu em 30/12/2018 e os funcionários foram ouvidos e fizeram os reconhecimentos apenas em janeiro de 2020, ou seja, mais de 1 anos após o ocorrido.

Mais do que isso, todas as vítimas em diversos momentos dos relatos confundiram os roubos não sabendo especificar como se deu o fato em tela, quantos eram os meliantes e principalmente como se deram os reconhecimentos.

Ou seja, pelos relatos das vítimas, não é possível um decreto condenatório dado que se tem apenas um reconhecimento fotográfico feito em sede inquisitória, após um ano do fato que não foi confirmado em juízo.

Os policiais ouvidos, por sua vez, narraram uma extensa investigação por meio de filmagens e redes sociais, contudo, ainda que se aprecie como foram depurados os fatos, nos autos não constam elementos suficientes que liguem os réus aos crimes ora apurados.

A testemunha FAUSI PRATES EL KADRI aduziu que foram 39 inquéritos de roubos, de uma investigação em que foram roubadas duas lojas e a partir disso fizeram a investigação. Contaram com a participação das vítimas que passaram a trazer muito material e imagens e perceberam que se tratava da mesma pessoa. Identificaram pessoas nas mídias sociais que eles sempre comemoravam os roubos e se reuniam em uma Igreja Bola de Neve, e então pediram interceptação. Eles fizeram o roubo em Sorocaba, mas vazou que eles comemoravam nas mídias e por isso eles não usavam mais essas redes. Foram para a Igreja Bola de Neve, e ficaram nas proximidades quando por volta das 20h chegou o Ismael o interceptador e o Arlindo que era um dos chefes. Eles ofereceram dinheiro e veículos aos policiais. Recuperaram uma Tiguan, moto, arma. Então passaram a chamar as vítimas para fazer o reconhecimento, porque tinham duas lideranças principais o Silvio Bertacchi e o Arlindo que escolhiam quem ia participar de cada roubo. Identificaram mais de 30 pessoas na investigação.

Nesse caso foi feito o reconhecimento fotográfico e as vítimas reconheceram. O foco deles era nas grandes lojas de departamento e os telefones eram mandados ao nordeste. As vítimas reconheceram no caso. Não sabe se as imagens foram periciadas.

A testemunha EVERTON VALERIANO DA SILVA alegou que são da unidade especializada de Guarulhos e foram incumbidos de investigar um roubo no local e foi instaurado um inquérito. Com as investigações, descobriram que havia uma quadrilha especializada nesses tipos de assalto e tiveram informações de outras empresas vítimas, mais especificamente da Via Varejo que indicou roubos pretéritos e passaram informações e imagens das câmeras de segurança que confrontada com a investigação.

Identificaram o Arlindo que era o líder que estava sendo monitorado bem como do Silvio e posteriormente o David. Monitoravam a quadrilha por redes sociais porque eles comemoravam após o roubo agradecendo a Deus e iam até a Igreja fazer a comemoração e postavam, e após um desses roubos que conseguiram monitorar o Arlindo e o capturaram junto com o receptador. No dia foram apreendidas armas, veículos, moto e dinheiro. No presente caso confrontaram com as imagens, acredita que tenha sido feito reconhecimento fotográfico. São cerca de 40 inquéritos, não sabe dizer se nesse caso houve o reconhecimento fotográfico. Não sabe se houve perícia das imagens. Não reconhece as pessoas da foto 506/507.

A testemunha CLAUDIO TADASHI SATO GAZAFI afirmou que foi feita uma investigação em Guarulhos que nas pesquisas caíram varios roubos e então chamara as outras vítimas que reconheceram os réus pelas filmagens. Não sabe se as fotos mostradas eram das filmagens ou de redes sociais. Iam mostrando uma foto por vez. Desse caso específico não sabe dizer como foram feitos os reconhecimentos. Não sabe se as

imagens dos lojistas foram submetidas a perícia.

Apesar das investigações narradas, nada disso consta no feito, há um relatório de fls. 20/25 que menciona os roubos nos mesmos formatos, porém não identifica os réus com imagens de câmeras de segurança nítidas ou que sejam do dia dos fatos ora apurados.

Da mesma forma, não foram juntadas as supostas comemorações feitas nas redes sociais, os bens apreendidos, ou qualquer outro elemento que indicasse a participação dos réus neste delito específico.

Por outro lado, os informantes de defesa de David disseram que no dia dos fatos ele estaria viajando juntando ainda fotos que são provas ao menos indiciárias de um alibi o que não foi afastado pela acusação (fls. 504/509)

Ainda, diferente do apontado pelo Ministério Público a pessoa de nome Alexandre Azevedo que consta na faixa preta das fotos (fl. 507) seria uma pessoa que curtiu a foto postada na rede social, não indicando qualquer coisa ou qualquer relação, até porque qualquer pessoa pode curtir fotos de redes sociais alheias de contas abertas.

O informante de defesa Elton disse que é cunhado do David. E que todo ano fazem uma viagem para praia e que foram viajar para Itanhaém em 27 de dezembro de 2018 e voltaram dia 03 de janeiro de 2019. Geralmente vai toda a família. Nos três últimos anos foram para Itanhaém. Ele trabalhava em uma pizzaria. Morava com a esposa dele. Olhando a foto de 505 disse que é a pessoa que está tirando a foto de óculos, o David é o sentado de bermuda preto e branca. Nas fls 506 disse que o réu é o de foto. Alexandre é o primo da esposa do réu Karollyn.

A informante Karollyn afirmou ser esposa do réu David, disse que na data dos fatos estava na praia com a sua família que vão todo ano, é uma tradição familiar, que foram na madrugada do dia 27 de dezembro. Foram para Itanhaém, cada ano procuram uma casa diferente. O David fazia bico na pizzaria. Nas fls. 509 disse que o David esta na boia rosa e na de 506 o de boné do lado da depoente. Não tem ninguém com nome de Alexandre na sua família.

Ou seja, o que se tem é que todos os delitos que tinham os mesmos modus operandi foram imputados às mesmas pessoas, porém não foram trazidos elementos suficientes para que o crime ora apurado do dia 30/12/2018, e não outros, que levassem a crer que os réus tiveram qualquer participação.

Assim, os réus (i) foram reconhecidos fotograficamente 1 ano após os fatos; (ii) tal reconhecimento não foi confirmado em juízo; (iii) os réus não foram detidos com quaisquer bens relacionados ao feito; (iv) não foram juntadas as fotos das redes sociais da investigação realizada; (v) não há notícias da relação entre os corréus, (vi) não há as imagens das câmeras de segurança do dia dos fatos 30/12/2018 e por fim (vii) as vítimas prestaram depoimentos inseguros não conseguindo nem mesmo identificar quais dos roubos estavam sendo tratados, sendo a absolvição medida que se impõe.

Assim, o desrespeito às normas legais no reconhecimento fotográfico, somado a fragilidade de provas, em especial o não reconhecimento inicial pelos ofendidos em juízo e os demais pontos acima mencionados, e as circunstâncias fáticas não é possível um decreto condenatório.

Nesse sentido foi o julgado recente do STJ do qual transcrevo algumas partes: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um

reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. (HABEAS CORPUS Nº 712781 - RJ (2021/0397952-8) RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ)

Como bem ponderou o ministro neste julgado:

O maior problema dessa dinâmica adotada pela autoridade policial está no seu efeito indutor, porquanto se estabelece uma percepção precedente, ou seja, um pré-juízo acerca de quem seria o autor do crime, que acaba por contaminar e comprometer a memória. Ademais, uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto. 8. Em verdade, o resultado do reconhecimento formal depende tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos externos que podem influenciá-lo, como o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso), a gravidade do fato, as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.), a natureza do crime (com ou sem violência física, grau de violência psicológica), o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento etc

Nesse sentido também é o entendimento doutrinário:

No que refere ao reconhecimento de pessoas, a maleabilidade e a função de aprender geram um efeito não desprezível: quando um rosto é apresentado a uma vítima e esta o reconhece como sendo autor do crime, seu cérebro "aprende" que o rosto reconhecido é o rosto visto no local do crime. Assim, todo reconhecimento é impactado diretamente por reconhecimentos anteriores, sendo o primeiro reconhecimento a oportunidade em que se pode ter acesso à memória mais livre de contaminações possível. Ou seja, um reconhecimento feito em Juízo utilizando métodos adequados não tem a capacidade de remediar os efeitos de um primeiro reconhecimento irregularmente produzido. Sendo o primeiro reconhecimento primordial para a identificação de autoria, é preciso zelar pela sua adequada realização.

(MATIDA, Janaina; CECCONELLO, William. Outra vez sobre o reconhecimento fotográfico. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-out-01/limite-penal-outra-vez-reconhecimento-fotografico>. Acesso em: julho. 2022)

Fica claro assim que o reconhecimento inicial realizado afeta todos os subsequentes, de modo a reforçar ainda mais a importância de que ele seja feito mediante um procedimento que assegure a lisura do ato, em especial quando que se tem a compreensão de que o reconhecimento de pessoas é considerado como uma prova cognitivamente irrepetível.

Em suma, da prova oral produzida em juízo não se extraem elementos suficientes para um decreto condenatório.

Desta feita, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que, no processo criminal, o decreto condenatório exige certeza absoluta, baseada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubitosa, o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade de serem os acusados os autores do fato criminoso. Em razão disso, já se decidiu: "A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível criminoso é condenar um possível inocente". (TJSP - AC 142.227-3 - Rel. Nelson Fonseca - JTJ 170/315).

Ademais, analisando o conjunto probatório, conclui-se que não há uma única prova, produzida em juízo, no sentido de que o acusado tenha sido um dos autores do grave crime cometido.

Tal circunstância, desacompanhada de provas judicializadas da autoria, não permite que se chegue a um decreto condenatório.

Tal proteção ao contraditório é de tanta importância que na reforma legislativa de 2008, foi incluída expressamente essa previsão no artigo 155 do Código de Processo Penal que diz: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EMBASADO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. EXPRESSA DESCONFORMIDADE COM A REGRA PREVISTA NO ARTIGO 155 DO CPP.

OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

ORDEM CONCEDIDA. 1. Em respeito à garantia constitucional do devido processo legal, a legitimidade do poder-dever do Estado aplicar a sanção prevista em lei ao acusado da prática de determinada infração penal deve ser exercida por meio da ação penal, no seio da qual ser-lhe-á assegurada a ampla defesa e o contraditório. 2. Visando afastar eventuais arbitrariedades, a doutrina e a jurisprudência pátrias já repudiavam a condenação baseada exclusivamente em elementos de prova colhidos no inquérito policial. 3. Tal vedação foi abarcada pelo legislador ordinário com a alteração da redação do artigo 155 do Código de Processo Penal, por meio da Lei n. 11.690/2008, o qual prevê a proibição da condenação fundada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. 4. Constatado que o Tribunal de origem utilizou-se unicamente de elementos informativos colhidos no inquérito policial para embasar o édito condenatório em desfavor do paciente, imperioso o reconhecimento da ofensa ao aludido dispositivo do Estatuto Processual Penal, já em vigor na data da prolação do acórdão objurgado, bem como à garantia constitucional ao devido processo legal. 5. Ordem concedida para cassar o acórdão condenatório apenas com relação ao paciente, restabelecendo-se a sentença absolutória proferida pelo magistrado singular, com a determinação de expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - HC: 123295 MT 2008/0272631-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 29/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2009)

A unilateralidade das investigações desenvolvidas pela polícia judiciária na fase preliminar da persecução penal e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito, eis que é somente em juízo que se torna plenamente exigível o dever de observância ao postulado da bilateralidade de da instrução criminal contraditória.

A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao procedimento de investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência dos tribunais, cujo magistério tem acentuado que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da persecução penal em juízo.

Nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia.

EMENTA: I. Habeas corpus: falta de justa causa: inteligência. 1. A previsão legal de cabimento de habeas corpus quando não houver "justa causa" para a coação alcança tanto a instauração de processo penal, quanto, com maior razão, a condenação, sob pena de contrariar a Constituição. 2. Padece de falta de justa causa a condenação que se funde exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial. II. Garantia do contraditório: inteligência. Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação. STF, RE 287658 / MG - MINAS GERAIS Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE Julgamento: 16/09/2003

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO os réus DAVID HAISLAN GOMES DE PAULA, SILVIO BERTACCHI FILHO e ARLINDO DE SOUZA E SILVA NETO , qualificado nos autos, das sanções do artigo art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razão da absolvição, faculto eventual apelo em liberdade.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe.

Custas não são devidas.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA